

1502618-32.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305719/2021 - 04º D.P. OSASCO, 21301425 - 04º D.P. OSASCO, 734/21/417 - 04º D.P. OSASCO, 2305719 - 04º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502618-32.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502618-32.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305719/2021 - 04º D.P. OSASCO, 21301425 - 04º D.P. OSASCO, 734/21/417 - 04º D.P. OSASCO, 2305719 - 04º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO JOSE DA CONCEICAO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual LEONARDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra denúncia, fls. 71/74, que, no dia 09 de novembro de 2021, às 12h15min, na Rua Salvador, 242, Rochdale, nesta cidade e Comarca de Osasco, LEONARDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, qualificado à fl. 05, trazia consigo e guardava drogas, consistentes em 16 (dezesseis) porções de cocaína, no total de 6,9g (seis gramas e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, conforme auto de exibição e apreensão à

fl. 09, laudo de constatação de fls. 11/13 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos.

Narra, ainda, a inicial acusatória, que, segundo o apurado, na data dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o denunciado, o qual, ao notar a presença da viatura, tentou se evadir e entrou em uma residência. Em frente ao local, a testemunha Carolina, irmã do denunciado, autorizou a entrada dos policiais militares na residência, onde encontraram, nos fundos da casa, a bolsa dispensada pelo denunciado, a qual continha 16 (dezesesseis) eppendorfs de cocaína, além da quantia de R\$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais) em notas trocadas. Na ocasião, o denunciado negou que comercializava entorpecentes. Em sede policial, o denunciado permaneceu em silêncio. Pela forma de acondicionamento das drogas, quantidade e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, notadamente a presença de significativa quantia de dinheiro em notas trocadas, bem como o depoimento da testemunha Carolina, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros. É dos autos que o denunciado recentemente foi condenado por delito análogo, consoante se verifica da certidão de fls. 24/26.

Auto de exibição e apreensão às fls. 9.

Foto dos entorpecentes 10.

Laudo Pericial Definitivo às fls. 101/103 e 159/161.

Antecedentes e certidões em nome do acusado às fls. 85/94 e 95/97.

Em decisão de fls. 38/40 a prisão em flagrante foi convertida em provisória. Às fls. 54/65 foi protocolado por parte do advogado do acusado o pedido de revogação, às fls. 81/82 o pedido foi indeferido.

Mandado de prisão cumprido às fls. 76/80.

O acusado constitui defesa às fls. 66 e apresentou defesa prévia por intermédio de seu defensor constituído às fls. 107/112.

A denúncia foi recebida às fls. 120/126.

Em decisão de fls. 155/156 foi decidido a manutenção da prisão preventiva.

A audiência designada para 29 de março de 2022 não pode ser realizada em razão da ausência das testemunhas.

O acusado está preso.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas e o réu, ao final, interrogado.

Em audiência anterior (fls. 169/170) o Ministério Público desistiu da oitiva da irmã do acusado (Carolina).

Em debates o Ministério Público pediu a condenação nos termos da inicial. Requereu, ainda, o regime fechado e o reconhecimento dos maus antecedentes.

Também em debates, a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

É o breve relatório

Fundamento e decido.

O pedido é improcedente.

Com efeito, a finalidade epistêmica do processo penal é a busca da verdade, ainda que de forma aproximada, por meio de reconstrução fática que leve a superação do postulado da presunção de inocência. Entretanto, este objetivo teleológico deve ser buscado com respeito as regras legais e constitucionais de produção e valoração das provas. Não é possível, dentro de um processo penal de índole democrática, a valoração da prova ser dissociada da ideia de legalidade. A legalidade da prova é um pressuposto do juízo de mérito. O processo não é um fim em si mesmo e a verdade não pode ser buscada a qualquer custo, ainda mais havendo sacrifício de direito individual. Antes de qualquer valoração racional é sempre necessário o escrutínio da fonte da prova.

Nesse sentido: “assim, no Brasil, os códigos processuais, civil e penal, dispõem justamente acerca da validade da prova da verdade, que deverá seguir um trâmite que não cause surpresa às partes (livre acesso), que amplie sua participação no discurso relacionado ao seu enunciado (contraditório), que seja adequada e idônea ao fato que se quer provar e que não seja obtida por meios ilícitos. A busca da verdade não é, assim, orientada para a obtenção da verdade substancial, mas apenas da verdade provavelmente admitida. Não vigora mais, assim, no processo a busca da verdade real. Até porque, como já se disse, não existe essa suposta verdade real. Seria uma pretensão audaciosa do direito entender que o juízo possa fazê-lo unicamente pelos instrumentos legais.” (TAVARES, Juarez, CASARA, Rubens. Prova e verdade. 1ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 147).

O Código de Processo Penal, saliente-se, adotou o sistema do livre convencimento objetivo motivado do juiz, pelo qual incumbe ao magistrado formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que fundamentadamente. Em outras palavras, não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base em elementos colhidos ao arrepio de direitos individuais. O material probatório levado à análise judicial deve se revestir de legalidade, o que não se verifica no presente caso. A sentença, portanto, é fundamentada em dois argumentos e ambos convergem para a absolvição: a) o primeiro é que toda prova é ilícita pois deriva de violação de direito constitucional – ingresso em domicílio sem justa causa prévia, fora, portanto, das hipóteses constitucionais; b) o segundo é que, mesmo que superado o argumento anterior, a versão dos policiais (notadamente em relação a verem o réu dispensando uma sacola ou mochila ou bolsa no quintal) é totalmente dissonante e sem elemento externo de corroboração.

A dinâmica fática relatada pelos policiais, em resumo, consiste no fato de que estavam em patrulhamento e avistaram um veículo suspeito. Este veículo entrou para o bairro e, por este motivo, o perderam de vista. Iniciaram patrulhamento na região com vistas a localizar referido veículo. Quando passavam na rua local dos fatos, em frente a casa do réu, avistaram o réu, a irmã e o pai dentro da residência (especificamente perto da escada, no quintal). O réu, então, teria ficado nervoso e corrido para dentro da residência. Os policiais, na sequência, por esta razão, teriam desembarcado da viatura e pedido autorização para ingressarem na residência. Após a autorização da irmã do réu (não ouvida em audiência) localizaram o réu (há divergências quanto ao local da localização) sem antes avistarem (ponto nebuloso da prova) o réu lançar um bolsa no quintal, no qual havia um cachorro. Após a dona da residência segurar o cachorro, lograram encontrar as drogas descritas na inicial dentro da bolsa/sacola/mochila.

Com efeito, anote-se que, mesmo sendo o crime do art. 33 da Lei de Drogas de natureza permanente, especialmente os núcleo típico guardar (este imputado na denúncia), fixou o Superior Tribunal de Justiça, por meio de atividade interpretativo-teleológica no sentido de trazer conteúdo concreto ao pressuposto legal “fundadas razões” (expressão jurídica indeterminada), no voto condutor do Ministro Rogério Schietti, alguns standard probatórios para validade da prova, dentre eles haver fundadas razões que justifiquem a entrada em domicílio alheio fora as hipóteses constitucionais, que devem ir além da “mera atitude suspeita” ou “fuga do indivíduo em direção a sua casa”. (Habeas Corpus n. 598.051 – SP. Rel.

Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - 6ª Turma, j. 02.03.2021). Anote-se, por oportuno, que este leading case orientou a unificação do entendimento das duas turmas do Superior Tribunal de Justiça no (Habeas Corpus n. 616.584 - RS - Rel. Min. RIBEIRO DANTAS - 5ª Turma, j. 30.03.2021).

Assim:

(...)

2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva.

(...)

4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

(...)

6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio.

(...)

7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.

(...)

Saliente-se, por oportuno, que a questão aqui apreciada já foi objeto de amplo debate na jurisprudência também do STF. O Pleno da Suprema Corte, por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616-RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 05/11/2015, fixou a seguinte tese de repercussão geral: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Postas estas premissas jurisprudenciais-doutrinárias, no caso dos autos percebe-se que a prisão do acusado derivou de simples desconfiança policial e nada mais. Em

primeiro lugar, os policiais patrulhavam o local com vistas a encontrar um veículo suspeito que haviam perdido o contato visual. Não há relação entre este argumento (diligências para localização de um veículo) e o ingresso na residência e posterior apreensão de drogas. Há, portanto, claro desvio de finalidade na conduta dos policiais até porque sequer perseguição houve e o veículo não estava dentro da residência. O encontro das drogas no quintal se deu de modo fortuito eis que não estava no espectro de alcance da atividade policial a apreensão de drogas. Em segundo lugar, o acusado se encontrava dentro da própria residência e a alegação de que se mostrou nervoso ao ver a viatura que estava na via pública não é minimamente suficiente para a compreensão das “fundadas razões”; em terceiro lugar, e mais importante, não há demonstração de que houve anuência expressa ou tácita, livre e consciente, do acusado ou de quem de direito (morador da casa) para o ingresso domiciliar.

Quanto a este ponto, a irmã do acusado, quem teria autorizado o ingresso na residência, não fora ouvida eis que houve desistência de sua oitiva na audiência anterior por parte do Ministério Público. E mais, conforme relatado pelas próprias testemunhas policiais, estes, ao verem o acusado dentro da residência, desembarcaram da viatura, com armas em punho (seguindo o protocolo da polícia militar) e, neste contexto e neste momento, teriam pedido “autorização” para ingresso na residência. Trata-se de verdadeiro constrangimento situacional do qual não se pode extrair validade para ingresso na residência.

Portanto, a acusação não trouxe provas seguras de anuência do acusado ou de quem de direito para a invasão domiciliar. A simples afirmação dos policiais de que a irmã do acusado teria assentido com a entrada não é suficiente. Necessários outros elementos de prova como, aliás, já fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sobreleva notar que, ainda que não se exija seja a anuência para ingresso domiciliar filmada, como afirmado no RE 1342077 – Min. Alexandre de Moraes, é fato que outros elementos de prova devem existir a demonstrar que a autorização foi livre e ausente qualquer tipo de pressão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 12G (DOZE GRAMAS) DE COCAÍNA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E EM ATITUDE SUSPEITA DOS ACUSADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas – 12g (doze gramas) de cocaína –, quando apoiado em mera denúncia anônima e no fato de que os policiais, de fora, avistaram os acusados no interior da casa manipulando material, não traz contexto fático que justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no caso dos autos. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RECURSO ESPECIAL nº 1.865.363 - SP – 6ª Turma – Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – 22.06.2021).

Por outro lado, ainda que se supere o escrutínio de legalidade, as provas não demonstram, com a segurança, para além da dúvida razoável, a premissa fático-acusatória de que o acusado trazia consigo e guardava drogas, consistentes em 16 (dezesseis) porções de cocaína, no total de 6,9g (seis gramas e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória não é suficiente a justificar a reponsabilidade penal do réu.

A existência material do crime restou demonstrada nos autos por meio dos laudos periciais (fls. 101/103 e 159/161). Entretanto, quanto a autoria as provas valoradas em contraditório judicial não permitem com a segura e devida convicção o decreto condenatório do réu em relação ao delito de tráfico (art. 33 “caput”). Em outras palavras, as incongruências apresentadas pelos policiais, unidas à falta de outros elementos que comprovem a diligência, para além da versão extraída da

memória, não apresentam uma garantia epistêmica suficiente que justifique a imposição de pena.

O réu, em juízo, negou os fatos. Afirmou que estava em casa lavando roupa. Os policiais entraram e determinaram que se deitasse no chão. Os policiais viram sua intimação em um processo no qual fora condenado. Pediram dinheiro. Negou-se a dar dinheiro e, por esta razão, afirma ter sido “forjado”. Tudo se passou dentro de sua casa.

A testemunha Carlos Roberto, afirmou que, junto com seu colega, estavam em patrulhamento com vistas a um veículo. Perderam o veículo de vistas. Entraram na rua local dos fatos. Passaram pela rua olhando para ver se o veículo estava em alguma garagem. O réu estava próximo a um portão/escadas, no quintal da residência. Ele correu para dentro da residência. Estavam também a irmã e o pai. Relata que o réu viu os policiais e correu para dentro. Afirmar que perguntou a “uma mulher e um senhor se poderia entrar na casa” porque alguém teria entrado correndo. Relatou, ainda, que o réu entrou para dentro do quarto e neste cômodo dispensou para fora da residência uma mala. Havia um cachorro. Não pegaram a mala no momento pois havia um cachorro. Havia um caderno com folhas rasgadas que parecia se contabilidade de tráfico, mas não apreenderam. Disse que o réu relatou que correu porque estava respondendo por outro crime. Perguntaram o que réu tinha jogado, mas ele não respondeu. Pediram para retirar o cachorro. Encontraram uma mochila com alguns eppendorfs. Afirmou que os eppendorfs continham cocaína. Também havia uma quantidade de dinheiro. Afirmar que foi o réu quem rasgou o caderno. Relatou que foram o pai e a irmã que autorizaram a entrada na residência. Visualizaram o réu jogando algo, a princípio uma bolsa. Não viram detalhes da bolsa e, por fim, a residência era somente da família.

A testemunha Giovanni, ao contrário do afirmado pela testemunha Carlos Roberto, após relatar a dinâmica de ingresso, afirmou que, no momento, o réu olhou os policiais com uma sacola na mão e jogou-a para trás. Na sacola havia drogas e dinheiro. Também havia um caderno rasgado com contabilidade do tráfico, o qual não foi apreendido.

Assim, coligindo os relatos dos policiais não há provas seguras de o réu guardava drogas.

Os policiais não souberam afirmar o momento que o réu teria dispensado a sacola ou a mala com drogas., tampouco o local no qual ele estava quando jogou o objeto, nem mesmo o momento que teria dispensado a droga. Também não souberam informar a quantidade de drogas e também de dinheiro. Soa estranho, também, que visualizaram um caderno com anotações de tráfico o qual, ainda que rasgado, não fora apreendido para servir de alguma forma como elemento de prova.

Ainda, diferentemente do que consta na inicial, não havia patrulhamento de rotina, mas sim os policiais buscavam um veículo que se evadiu o qual, anote-se, não estava na garagem da casa do réu – o que poderia justificar o ingresso no domicílio, como salientado. E mais, o réu não correu para dentro de casa pois, como se depreende da prova, ele já estava nos limites de sua residência, na parte interna.

Anote-se que nesta fase de valoração da prova a qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é porque a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com as demais provas apresentadas. No caso dos autos, as testemunhas policiais apresentam versões claudicantes e pouco plausíveis, e, acima de tudo, não podem ser corroboradas por outros elementos de prova, eis que a diligência não fora registrada por qualquer mecanismo de gravação e, ademais, sequer motivo para ingresso na residência.

Portanto, a versão do réu não restou suficientemente afastada. As provas não foram capazes de superar o postulado da presunção de inocência.

A única certeza dos autos é o encontro da droga. Entretanto, a autoria por parte do acusado das condutas típicas afirmadas pela acusação na inicial, com base nas

provas colhidas em contraditório judicial, permanece obnubilada.

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria. A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido em contraditório judicial. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação penal e ABSOLVO LEONARDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Determino a destruição do entorpecente. Oficie-se.

Quanto ao dinheiro apreendido, fica autorizada a devolução.

Após o trânsito em julgado, diante da violação do espaço de liberdade representado pelo domicílio, asilo inviolável nos termos da Carta Constitucional, e dos indícios de que estes limites não foram respeitados pelo Estado, o que sinaliza um violência estatal, determino oficie-se a Corregedoria da Polícia Militar para apuração da conduta dos policiais, e de possível incidência do art. 22 da Lei n. 13.869/2019.

P.R.I.C.

Ciência ao Ministério Público.

Osasco, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA